

1500575-98.2022.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Éverton Willian Pona

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/10/2022

... para a apuração do delito de tráfico de entorpecentes.

Não há preliminares a serem apreciadas ou nulidades a serem declaradas. O mérito há de ser conhecido.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes

A materialidade da conduta imputada ao réu encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capão Bonito

Foro de Capão Bonito

2ª Vara

Rua Rafael Machado, 50, Capão Bonito-SP - cep 18304-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500575-98.2022.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500575-98.2022.8.26.0571

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108676/2022 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 24445954 -

DEL.POL.CAPÃO BONITO, 2108676 - DEL.POL.CAPÃO BONITO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS BEZERRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Éverton Willian Pona

Vistos.

1 RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública, sob o rito ordinário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS BEZERRA, já devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo consta na denúncia (fls. 83-85), no dia 20 de abril de 2022, à noite, na Rua Pedro Gonçalves de Almeida, Vila Aparecida, nesta cidade e comarca, MARCELO,

trazia consigo, para fins de tráfico, de 17 porções de maconha, com massa bruta total de 15,61 gramas; 15 porções de cocaína, com massa bruta total de 0,33 gramas; e 74 porções de crack, com massa bruta total de 11,72 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 14/15 e auto de constatação a fls. 14/15).

De acordo com o Ministério Público, o réu caminhava pela rua e correu ao ver uma guarnição da Polícia Militar, o que chamou a atenção de seus integrantes, que o abordaram. Realizada a revista pessoal, as drogas acima descritas foram apreendidas com ele, dentro de uma bolsa, individualmente embaladas e prontas para a venda, além de R\$ 335,00 em cédulas e moedas, e um telefone celular (cf. imagens a fls. 21/23).

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, acompanhadas de dinheiro, comprovam o narcotráfico para o Ministério Público.

Acompanharam os autos deste processo o recebimento da denúncia às fls. 87-89, seguindo-se a regular citação do réu às fls. 113, com posterior apresentação de resposta à acusação (fls. 142-143).

Realizou-se audiência de instrução na qual foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu. Nada foi requerido na fase no art. 402, do Código de Processo Penal.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa requer a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal, com os consectários daí decorrentes.

É o relatório. Passo à fundamentação e decisão.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal instaurada para a apuração do delito de tráfico de entorpecentes.

Não há preliminares a serem apreciadas ou nulidades a serem declaradas. O mérito há de ser conhecido.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes

A materialidade da conduta imputada ao réu encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08-10) auto de exibição/apreensão (fls. 12-13), auto de constatação preliminar (fls. 14-15), fotos do material apreendido (fls. 22-23), laudo pericial exame químico-toxicológico (fls. 117-120, 121-124 e 125-128) e pela prova oral colhida em juízo. Em relação à autoria, de se considerar que o réu, na fase policial, disse que: é usuário de maconha; estava no local para comprar drogas; quando viu o farol vindo, todo mundo saiu correndo; o interrogado também saiu correndo; um policial o pegou correndo; na pochete tinha seu celular, documentos, aproximadamente a quantia de duzentos reais e em seu bolso a quantia de vinte reais; não tinha nenhuma droga em seu poder ou em sua pochete; no ano de 2010 trabalhava como disque moto e foi preso acusado de tráfico de drogas, ficando preso até o ano 2016 em CDP, Penitenciária e Colônia; não estava com drogas em seu poder e não cometeu o crime de tráfico do qual está sendo acusado; está recebendo a rescisão de contrato com a empresa Comerplast e atualmente esta trabalhando como pedreiro autônomo. (fls. 04).

Interrogado em juízo disse que: no dia dos fatos estava trabalhando e recebeu dinheiro; foi ao local buscar drogas pois é usuário; havia outras pessoas no local e quando viu o farol, saiu correndo; estava com a pochete, mas eram seus documentos e seu celular; faz parte da mesma igreja da testemunha Alan, que o humilha e o desrespeita; não estava com as drogas; não sabe porque dizem que estava com a droga; chegou um reforço policial e ficaram procurando uma meia hora no meio da mata; a maconha foi encontrada dentro de um "copão"; o depoente disse que era usuário; o policial voltou no mesmo lugar em que estava a maconha e encontrou uma bolsa térmica vermelha com as demais drogas apreendidas; as drogas não estavam com o depoente; no dia anterior aos fatos foi abordado pelos mesmos policiais.

A testemunha, Anderson Adriano Ferreira, policial militar, ouvido em solo policial, disse que: é policial militar; estava em patrulhamento com CBPM Alan na Vila Aparecida; no dia dos fatos, o réu ao notar a aproximação da viatura tentou se evadir saindo correndo; foi abordado pelo depoente; em revista pessoal foi encontrado com o mesmo uma bolsa pequena tipo "pochete" contendo os entorpecentes, 74 pedras de crack, 17 trouxinhas de maconha e 17 eppendorf de cocaína, além da quantia de R\$ 335,00 em dinheiro, bem como um aparelho celular; o réu apresentou RG, sendo identificado como MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS BEZERRA; em consulta apresentou passagem pelo artigo 33 trafico de drogas; o réu preferiu ficar em silêncio sendo dado voz de Prisão e apresentado à Autoridade Policial. (fls. 02). Em juízo relatou que: estavam em patrulhamento de rotina no local que é conhecido como ponto de tráfico de drogas; MARCELO não havia notado a presença da equipe; quando ele percebeu a chegada da viatura ele tentou correr para um terreno baldio; o depoente desembarcou e correu atrás do réu; conseguiu alcança-lo; o réu tinha uma pochete com maconha, cocaína e crack, além de dinheiro trocado; o local é bastante frequentado por usuários de drogas; já abordou o réu em outras oportunidades em região de tráfico de drogas; nas outras abordagens nunca encontrou drogas com eles; não prestou atenção de havia outras pessoas próximas pois focou no réu, que havia corrido; pochete estava com o réu.

A testemunha, Alan Aires Vieira, policial militar, ouvido em solo policial, disse que: é policial militar; estava em patrulhamento com SDPM Adriano na Vila Aparecida; no dia dos fatos, o réu ao notar a aproximação da viatura tentou se evadir saindo correndo; foi abordado pelo SD Adriano; em revista pessoal foi encontrado com o mesmo uma bolsa pequena tipo "pochete" contendo os entorpecentes, 74 pedras de crack, 17 trouxinhas de maconha e 17 epeendorf de cocaína, além da quantia de R\$ 335,00 em dinheiro, bem como um aparelho celular; o réu apresentou RG, sendo identificado como MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS BEZERRA; em consulta apresentou passagem pelo artigo 33 trafico de drogas; o réu preferiu ficar em silêncio sendo dado voz de Prisão e apresentado à Autoridade Policial (fls. 02). Em juízo relatou que: estavam em patrulhamento com o policial Adriano quando viu um movimento grande de pessoas; uma pessoa saiu correndo e o motorista da viatura desembarcou rapidamente e conseguiu segurar o MARCELO; com ele tinha uma pochete com dinheiro e três tipos de drogas; na hora da abordagem o réu nada disse; apenas MARCELO correu; já conhecia MARCELO de abordagens policiais; não frequentam a mesma igreja;

Reinaldo Rodrigues de Campos, ouvido como informante, disse que: estava no dia dos fatos "bebendo uma pinguinha"; visualizou a abordagem e o réu não portava nenhum objeto; estava noite e não conseguiu ver direito; sabe que o réu usava maconha. Adauto Roque, ouvido como informante, disse que: conhece o réu e trabalham juntos quando MARCELO está desempregado na construção civil; sabe que o réu fuma maconha; No que tange ao depoimento de policiais, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprir em seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no

âmbito do devido processo legal". (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

No caso sob análise, a atuação dos agentes policiais revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. Os depoimentos dos policiais foram seguros, coesos e harmônicos entre si, dotados de credibilidade e com força probatória. Nada existe de concreto nos autos a indicar que os policiais ouvidos em juízo estivessem tentando incriminar falsamente o réu, atribuindo-lhe o falso cometimento de um delito.

Do contexto probatório dos autos extrai-se que o réu nega a posse dos entorpecentes e afirma que se dirigiu ao local apenas para a compra de entorpecentes. Segundo sua versão, as drogas foram encontradas na mata próxima ao local dos fatos pelos policiais que atribuíram a ele a propriedade. Argumenta que frequenta a mesma igreja que a testemunha Alan e que o policial o humilha e desrespeita por conta do vício.

A testemunha Alan, entretanto, apesar de devidamente questionada pela Defesa, negou ser da mesma congregação religiosa do réu. E seu depoimento é consentâneo com o da testemunha Anderson, o policial que efetivamente diligenciou e realizou a apreensão do réu, que havia fugido ao notar a aproximação da viatura policial.

Assim, a versão do réu permanece isolada das demais provas dos autos. A Defesa menciona uma contradição nos depoimentos dos policiais quanto a existência ou não de outras pessoas. Contudo, não se observa a referida contradição, pois Anderson não negou a existência de outras pessoas, apenas disse que focou sua atenção no réu, pois o viu correr e imediatamente saiu do veículo em sua perseguição.

Em relação ao depoimento do informante Reinaldo, vê-se que seu depoimento não é digno de credibilidade pois como ele próprio admitiu, é consumidor contumaz de álcool e no dia estava no local justamente "tomando um pinguinha". Ele também afirmou que o local estava escuro. Por isso, a sua afirmação de que nada tinha o réu consigo, quando confrontada com as demais provas, não é suficiente para afastar a afirmação das testemunhas Anderson e Alan.

Portanto, não há dúvida sobre a ocorrência do fato delituoso e de sua autoria.

O réu, de forma consciente e espontânea, trazia consigo, para fins de tráfico, de 17 porções de maconha, com massa bruta total de 15,61 gramas; 15 porções de cocaína, com massa bruta total de 0,33 gramas; e 74 porções de crack, com massa bruta total de 11,72 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conduta que se amolda formalmente à previsão abstrata do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Restando preenchida a tipicidade formal.

Caracterizada, pois, a tipicidade formal objetiva, imperioso destacar a presença, também, da tipicidade material, ante a efetiva violação do bem jurídico protegido pela norma, bem como, dos elementos subjetivos do tipo. O réu agiu com dolo, nas modalidades cognitiva e volitiva, pois evidente tratar-se de conduta deliberada. O fato é típico, portanto.

Outrossim, não se verificam presentes quaisquer das causas excludentes da antijuridicidade da conduta, previstas no art. 23, do Código Penal. O fato descrito é, assim, típico e ilícito.

Além disso, o réu possui plena capacidade penal e pode ser responsabilizado por seus atos. É penalmente imputável e possui condições de compreender a ilicitude de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Segundo se observa nos autos, possuía conhecimento suficiente, à época dos fatos, para perceber a ilegalidade de sua ação e agir, se assim quisesse de outra forma. Optou pela conduta ilícita quando dele era exigível comportamento diverso. Por tais razões, a sua conduta é culpável.

Desse modo, por se tratar de fato típico, antijurídico e culpável, ausentes quaisquer causas de exclusão da ilicitude, culpabilidade ou de extinção da punibilidade, mostra-se imperiosa a condenação do réu MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS BEZERRA nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

2.2 Individualização da pena

Fixadas tais premissas, passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas. Adota-se, para a dosimetria da pena, o sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal.

2.2.1 Dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria a culpabilidade mostra-se normal e inerente ao delito; não constam maus antecedentes; não há informações sobre a conduta social ou sobre a personalidade do réu; os motivos são inerentes ao delito, assim como as circunstâncias e as consequências. Não se observa, por fim, qualquer contribuição do comportamento da vítima.

No caso de tráfico de drogas, deverá ser considerado com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei de Drogas). Quanto à natureza, observa-se ter sido apreendida maconha, cocaína e crack. Há maior reprovabilidade quanto a essa circunstância.

Crack, especialmente, apresenta potencial viciante maior, gerando com facilidade a drogadição. Além disso, o crack causa dependência extremamente forte e produz efeito social devastador, facilmente observado nos grandes centros urbanos, que sofrem com a concentração de viciados em referida substância em determinadas regiões, gerando, além de insegurança para a população ao redor de tais conglomerados de viciados, a reiteração de pequenas práticas delitivas praticadas por tais pessoas no intento de sustentar o vício.

Em recente reportagem veiculada em meio de comunicação de credibilidade nacional, afirmou-se que “pequenos municípios do país começam a viver o processo chamado de interiorização do crack. A droga é distribuída a partir das capitais e causa uma série de impactos sociais em locais com menos recursos”, como o caso de Capão Bonito.

Prossegue a reportagem afirmando que o crack “atinge pelo menos 86% dos municípios brasileiros, de acordo com levantamento do Observatório do Crack, criado pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios). Segundo os dados da entidade, 4.813 dos 5.568 municípios relataram ter registrado problemas ligados ao crack. Em mais de 20% deles, o nível de gravidade desses problemas é classificado como alto” e reproduz fala da pesquisadora e consultora do Observatório do Crack, Mariana Boff Barreto a qual afirma que “o crack é uma droga de alto poder ofensivo e um combustível para vários tipos de violência” e “Nessas cidades, cresceu muito o número de furtos, roubo, latrocínios, crimes também contra o próprio dependente, ou seja, vários tipos de violência correlacionada”.

Por essas razões, em razão não apenas do seu potencial viciante e destrutivo para a saúde do usuário, mas também pelas consequências sociais que a droga provoca, com aumento da criminalidade, o tráfico do crack deve receber reprimenda maior. Assim, considero negativa a natureza das substâncias.

Em relação à quantidade, foram apreendidos 17 porções de maconha, com massa bruta total de 15,61 gramas; 15 porções de cocaína, com massa bruta total de 0,33 gramas; e 74 porções de crack, com massa bruta total de 11,72 gramas. O montante já se mostra suficiente para ensejar maior reprovação, de modo que a circunstância deve ser considerada negativa.

Em relação ao quantum do aumento nesta fase da dosimetria prevalece na jurisprudência, em razão da ausência de previsão específica na legislação, competir ao magistrado sopesar as especificidades do caso concreto e atribuir o devido valor a cada uma das circunstâncias judiciais. Confirma-se:

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O CP não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 107.860, rel. min. Rosa Weber, 1ª T, DJE de 25-9-2012.)

O STF submete a legalidade da pena ao fundamentado exame judicial das circunstâncias do delito. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos da sanção, embasado nas peculiaridades do

caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. O art. 59 do CP confere ao juízo sentenciante o poder-dever de estabelecer uma reprimenda apta à prevenção e simultaneamente à reprovação do delito, sempre atento o magistrado à concretude da causa. Sucede que, em situações como a retratada nos autos, o juiz sentenciante há de considerar parâmetros que são próprios da legislação de drogas. Parâmetros constantes do art. 42 da Lei 11.343/2006. Pelo que o caso é de calibração das balizas do art. 59 do CP com as circunstâncias listadas na pertinente legislação extravagante. No caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da quantidade de droga apreendida. O que não discrepa da jurisprudência do STF (RHC 108.878, rel. min. Ayres Britto, 2ª T, DJE de 21-11-2011).

Em reflexão sobre a forma de atribuição do quantum atinente a cada circunstância judicial, este magistrado entende, em aperfeiçoamento a posicionamentos anteriores, que a majoração da pena nesta fase da dosimetria em um percentual fixo (1/6 ou 1/8) sobre a pena mínima abstrata prevista na legislação ignora por completo a previsão legislativa acerca do limite máximo da reprimenda estabelecido, tratando de forma igual crimes com gravidade distintas, o que, em última análise, viola o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

Isso porque a individualização da pena apresenta-se em três momentos distintos: o legislativo (cominação abstrata da pena), com a fixação dos limites mínimo e máximo da pena; o judicial, com o estabelecimento da pena in concreto; e no momento da execução da pena, quando tem influência o comportamento individual do apenado para a concessão dos benefícios previstos na legislação.

A fase legislativa, de cominação abstrata da pena, representa a reprovabilidade do corpo social em relação à conduta tornada crime. Assim, no momento da aplicação, ignorar que crimes com a mesma pena base podem ostentar penas máximas distintas corresponde a sobrepor-se à reprovação da conduta externada pela sociedade por intermédio dos legisladores.

Desse modo, por serem 10 as circunstâncias constantes no caput do art. 59, do CP, somadas, entende-se que o quantum a ser atribuído a cada uma delas é de, no mínimo, de 1/10 entre a diferença da pena mínima e máxima fixada para o delito. Contudo, forte na jurisprudência, as especificidades do caso autorizam ao magistrado a atribuir maior relevância a uma ou outra circunstância, desde que devidamente fundamentado.

Considerando que no presente caso reconheceu uma circunstância como negativa (os antecedentes, a natureza e a qualidade da droga), acresço ao piso 2/10 da diferença entre o mínimo e o máximo abstratamente cominado ao delito e fixo a pena base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, em relação às agravantes e atenuantes, está presente a agravante da reincidência (cf. fls. 167 e 170, autos nº 0005389-

54.2011.8.26.0624, da 1ª Vara - Foro de Tatuí, com trânsito em julgado em 18/11/2014 e extinção da pena em 03/09/2018), razão pela qual agravo a pena em 1/6 e fico na fase intermediária em 8 anos e 2 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Na terceira fase, considerando a reincidência do réu, não faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Não há causas de aumento de pena. Torno definitiva a reprimenda em 8 anos e 2 meses de reclusão e 816 dias-multa.

2.2.2 Regime inicial de cumprimento da pena

Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário esclarecer que o réu foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, o qual é equiparado ao hediondo e, por força do art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da determinação por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, em 27/06/2012. Assim sendo, não há vedação à fixação de regime inicial diverso do fechado, mesmo a condenados por tráfico de drogas, consoante o entendimento do STF, por força da necessária individualização da pena, que implica na necessidade de se observarem as

circunstâncias do caso concreto e de cada condenado.

Nos termos do art. 59, III, do Código Penal, considerando o requisito objetivo (a quantidade de pena fixada em 8 anos e 2 meses), o fato do réu ser reincidente e tendo em vista as circunstâncias judiciais (art. 33, §3º, do CP), a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado.

2.2.3 Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis

No caso, o réu foi condenado a pena superior a 4 anos e, portanto, não satisfaz o requisito objetivo para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44, I, do CP), nem para a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP).

2.2.4 Fixação do valor do dia-multa

Em atendimento ao disposto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do réu.

2.2.5 Detração

A aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (detração a ser realizada pelo juiz na sentença) carece de uma melhor regulamentação, visto ser dispositivo assemelhado aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais.

Nesse sentido, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação Criminal – Receptação. Sentença condenatória. Recurso Defensivo pleiteando o reconhecimento da detração para fixar o regime aberto para cumprimento da pena. Materialidade e autoria provadas - Réu surpreendido na condução de veículo produto de furto - Depoimento do policial que merece credibilidade, sendo coeso e harmônico em relação ao conjunto probatório - Confissão judicial do réu que corrobora as demais provas produzidas em juízo - Manutenção da condenação de rigor - Dosimetria das penas - Pena-base fixada no mínimo legal - Manutenção da compensação da circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por ausência de reclamo Ministerial - Entendimento predominante no sentido de que a reincidência prepondera sobre a confissão, nos termos do art. 67, do Código Penal - Vedação da reforma tio in pejus - Penas inalteradas - Regime inicial semiaberto que se mantém em razão da reincidência registrada - Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Detração da pena - questão que deve ser melhor analisada em sede de execução criminal - Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0068936-68.2016.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017)

Do teor do acórdão extrai-se:

No tocante a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendendo não ser possível sua aplicação, eis que inviável a análise de requisitos subjetivos [...].

No mesmo sentido, recente julgado da 8ª Câmara Criminal do Tribunal Bandeirante, na Apelação nº 016797-87.2012.8.26.048, Relator: Lauro Mens de Melo, donde se extrai que, "inicialmente, inviável entender-se que o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal pode ser considerado como alteração de regime inicial a partir de pena cumprida, funcionando como progressão indireta". Além disso, "trazer para o processo de conhecimento numerosos dados acerca da execução tumultuária o processo,

tornaria a prestação jurisdicional confusa e mais demorada, o que certamente vai de encontro aos interesses da defesa".

Com efeito, a progressão do regime por este juízo, em decorrência de custódia cautelar, requer o acesso a dados pessoais do réu, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os requisitos objetivo e subjetivo. Ademais, a detração somente pode ser adequadamente apreciada pelo juízo da execução, que pode analisar todas as condenações do réu e evitar que o mesmo período de custódia cautelar seja utilizado para abatimento das penas em mais de um processo.

Tal análise deve ser feita no âmbito da execução penal, pelo que deixo de realizar a detração.

3 DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS BEZERRA pela prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, às penas de 8 anos e 2 meses reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 816 dias-multa.

FIXO para ambos, o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

CONDENO o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP) e, com base no art. 15, III, da Constituição Federal, enquanto durarem os efeitos da condenação, DETERMINO a suspensão de seus direitos políticos.

4 DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Prisão preventiva

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva do réu por entender presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, já que demonstrou clara tendência à prática criminosa por ser reincidente, o que representa risco à ordem pública, e não constam informações acerca do endereço e trabalho, de modo ser necessária à garantia de cumprimento da lei penal.

Recomende-se a manutenção da custódia cautelar. Expeça-se a guia de recolhimento provisório.

4.2 Decretação de perdimento dos valores apreendidos

Decreto o perdimento dos valores apreendidos às fls. 12-13 por ser produto de atividade criminosa.

4.3 Determinações finais e comunicações

Comunique-se a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ) e, com o trânsito em julgado:

- a) Intime-se o réu para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, do CP e art. 480, das NSCGJ), bem como das custas judiciais no prazo de 60 dias (art. 480, §1º, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento da multa no prazo assinalado, extraia-se certidão da sentença nos termos do art. 480-A, das NSCGJ;
- b) Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ);
- c) Expeça-se de guia de recolhimento definitiva ou oficie-se aditando a guia provisória (art. 472, das NSCGJ) e mandado de prisão;
- d) Determino a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas e ainda não destruídas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006);
- e) Comunique-se a SENAD, para o fim previsto no art. 63, §§ 2º e 4º, da Lei nº.

11.343/2006, remetendo relação dos bens e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, os locais em que se encontram e a entidade ou órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente;
f) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Capão Bonito, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA